

1500435-68.2020.8.26.0172

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HALLANA DUARTE MIRANDA

Comarca: Eldorado

Foro: Foro de Eldorado Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... unicidade de desígnios para o fim de cometer delito de associação para o tráfico.

Assim, a autoria do delito de associação para o tráfico não está comprovada.

c) Aplicação do privilégio

Importante ainda ressaltar que, muito embora a ré Flávia não tenha sido condenada nestes autos por associação, fato é que já cumpriu pena pelo delito de tráfico de drogas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Eldorado

Foro de Eldorado Paulista

Vara Única

Rua Professor Francisco Canto, 14, Eldorado-SP - cep 11960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500435-68.2020.8.26.0172 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500435-68.2020.8.26.0172

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2300788/2020 - DEL.POL.ELDORADO,

15010868 - DEL.POL.ELDORADO, 588/20/102 - DEL.POL.ELDORADO, 2300788 -

DEL.POL.ELDORADO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado, Réu e Averiguado:

FLÁVIA FRANCINI DA COSTA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HALLANA DUARTE MIRANDA

I - RELATÓRIO

FLÁVIA FRANCINI DA COSTA, LUCIANE MARIA DA SILVA e STHEFANY JESUS DOS SANTOS foram processadas como incursoas no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque FATO 1º: Em momento desconhecido, porém até o dia 02 de dezembro de 2020, em local ignorado, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o delito descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; FATO 2º: No dia 02 de dezembro de 2020, por volta das 21h, num matagal próximo à Rua Presbítero Alício de Freitas, Vila Nova esperança, e em uma casa localizada na

Rua João Vitorino Ferreira, nº 197, Vila Nova Esperança, ambos nesta cidade e comarca, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela identidade de propósitos e unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico de drogas, 305 (trezentos e cinco) pinos plásticos; 08 invólucros plásticos; e uma embalagem plástica, todos contendo cocaína, com 423g (quatrocentos e vinte e três gramas) de massa no total; bem como uma porção de 6g (seis gramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta da denúncia às fls. 55/58:

Segundo apurado, FLÁVIA, STHEFANY e LUCIANE MARIA se associaram para a exploração do tráfico de drogas.

As denunciadas se reuniram para a realização conjunta da mercancia espúria, repartindo entre si as atribuições inerentes à individualização das substâncias em porções individuais, guarda e venda direta aos usuários, de maneira habitual e quase profissional.

Essa forma de organização, peculiar para a pequena cidade de Eldorado, e o relativo sucesso que acumularam no tráfico de drogas – vide o produto da apreensão – bem evidenciam que não o faziam apenas de forma ocasional.

Pois bem, nas condições de tempo e lugar descritas no segundo parágrafo, FLÁVIA, STHEFANY e LUCIANE MARIA guardavam e mantinham em depósito, em um matagal e bem assim na casa onde tinham se instalado, 305 (trezentos e cinco) pinos plásticos, 08 invólucros plásticos, e uma embalagem plástica, todos contendo cocaína, com 423g (quatrocentos e vinte e três gramas) de massa no total, bem como uma porção de 6g (seis gramas) de maconha, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06, auto de constatação preliminar de fls. 07 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a ser oportunamente juntado aos autos.

Ocorre que policiais militares, em patrulhamento de rotina, receberam a notícia de um popular de que FLAVIA e STHEFANY, já conhecidas dos meios pelo envolvimento com o tráfico de drogas, estavam realizando a mercancia espúria, e se deslocaram até o local indicado.

Nesse instante, eles divisaram um motociclista junto de FLAVIA, e STHEFANY saindo do matagal. O primeiro escapou sem ser identificado, mas FLAVIA e STHEFANY foram abordadas.

FLAVIA trazia consigo a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais), e a explicação de que aguardavam a entrega de uma pizza não convenceu.

Os policiais, então, iniciaram buscas no local de onde STHEFANY havia saído, e encontraram quatro kits contendo 14 pinos plásticos de cocaína cada um (num total de 56), e outros oito invólucros plásticos com a mesma substância, além da quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, distribuída em notas quebradas.

FLAVIA acabou por admitir que mantinha mais drogas em casa, e levou os militares até o seu endereço residencial. Lá se encontrava a terceira averiguada: LUCIANE MARIA.

Com a autorização das denunciadas, uma vistoria foi promovida no imóvel.

No primeiro quarto, havia uma mochila com o RG pertencente a LUCIANE. Nela, foram localizados R\$ 1.852,30 (um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos), divididos em notas amassadas e moedas, e oito comprovantes de depósito em conta bancária.

E, sob a dita mochila, foi apreendida uma sacola plástica preta, com 485 pinos plásticos vazios, 249 pinos plásticos com cocaína, e um saco plástico com 172g de cocaína a granel.

No segundo quarto, foi localizada mais uma porção de 6g de maconha.

Consta dos autos, Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/05), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 06), Auto de Constatação Preliminar (fl. 07), Termo de Declarações (fl. 08, 10), Termo de Interrogatório (fls. 13), Nota de Culpa (fl. 14), Requisição IML (fl. 21), Requisição de Substância Entorpecente (fls. 22/23), Requisição de Objeto (fl. 24), Fotos (fls. 60/72), Relatório Final (fls. 79/81), Laudo Pericial (fls. 112/129), Folha de Antecedentes Criminais (fls. 375/380, 384/387 e 390/391) e Certidão de feitos Criminais (fls. 381/383, 388/389 e 392/393).

A denúncia foi em recebida em 04 de dezembro de 2020 (fls. 106/107).

Citadas, as rés apresentaram resposta à acusação (fls. 259/261, 281/286 e 290/291). Ratificado o recebimento da denúncia às fls. 313/320.

Em 12 de maio de 2022 foi realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e procedeu-se com o interrogatório das rés.

Em alegações finais por memoriais (fls. 402/415), o Ministério Público requereu a procedência da pretensão acusatória e teceu considerações sobre a dosimetria das penas.

Por sua vez, a defesa de Luciane, em memoriais (fls. 417/427), sustentou pela improcedência da demanda, em razão da insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório e arguiu sobre a violação de domicílio.

A defesa de Flávia apresentou alegações finais às fls. 428/435, requereu a absolvição da acusada pelo crime do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06 diante da ausência dos requisitos e arguiu sobre a violação de domicílio.

Por fim, a defesa de Sthefany apresentou alegações finais às fls. 438/444, requereu a absolvição da ré e sustentou sobre a violação de domicílio.

II – FUNDAMENTAÇÃO

PRELIMINAR

As Defesas das acusadas sustentaram que houve violação de domicílio e, por consequência, as provas derivadas dessas circunstâncias são ilícitas.

Vejamos:

Quanto ao ingresso forçado, tem natureza excepcional e, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição da República de 1988 (CR/88), só se justifica em casos de prestação de socorro, desastre, flagrante delito e determinação judicial (neste último caso, durante o dia - CPP, art. 241).

No caso, não havia mandado judicial e não se cogita de desastre ou prestação de socorro. Logo, resta examinar se havia situação de flagrante delito ou consentimento válido para o ingresso na casa.

Quanto ao ingresso policial forçado por flagrante delito, depende de fundadas razões da ocorrência do flagrante (STF, RE 603.616/RO – Tema 280 da Repercussão Geral), para cuja configuração é insuficiente por si só a denúncia anônima, a qual deve ser corroborada por diligências prévias mínimas de averiguação da verossimilhança do fato noticiado. Sobre o tema, cf., por todos, STF, HC 106152/MS, j. 29/3/16; STF, RHC 117988, j. 16/12/2014; STF, HC 106664, j. 27/08/2013; STJ, HC 512.418/RJ, j. 26/11/2019; STJ, HC 442.363/RJ, j. 02/08/2018.

No caso, poder-se-ia compreender que haveria flagrante delito em razão da denúncia anônima de que estaria ocorrendo tráfico de drogas na residência. No entanto, o teor da denúncia anônima recebida não foi minimamente corroborada por diligências prévias do aparato policial. Ainda, segundo os depoimentos, a denúncia limitou-se em descrever que o tráfico de entorpecentes ocorria em uma rua e não na residência da acusada.

Insta frisar que o depoimento dos policiais foi vacilante sobre qual o fundamento que gerou o ingresso no domicílio e que em inúmeras audiências nessa Comarca os policiais relatam que "por denúncias de particulares que não aceitaram se identificar, saíram em averiguação, ingressando na residência com autorização dos supostos infratores". Esse relato é genérico e quase uníssono na maioria das diligências referentes ao tráfico de drogas, o que faz com que, neste caso, a situação seja vista com cautela e prudência, haja vista a imperativa necessidade de condução das ações com licitude.

Quanto ao ingresso policial consentido, no julgamento do HC 598.051/SP (Sexta Turma, DJe 15.3.2021), o Superior Tribunal de Justiça (i) fixou quais os requisitos de validade do consentimento do morador ao ingresso policial em domicílio sem mandado para busca e apreensão de natureza criminal e (ii) definiu qual a distribuição do ônus probatório e do meio de prova necessário para a comprovação da validade do consentimento do morador para o ingresso policial em domicílio.

Em relação (i) aos requisitos de validade do consentimento do morador, fixou-se a tese de que "[o] consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação".

A voluntariedade do consentimento deve então ser aferida à luz das circunstâncias do caso concreto (totality of circumstances, requisito, aliás, também exigido pela Suprema Corte dos Estados Unidos – cf. leading case: Scheneckloth v. Bustamonte, 412 U.S. 218, 1973). No mesmo sentido: STJ, HC 616.584/RS, Quinta Turma, DJe 6.4.2021. Vale dizer, devem ser analisados fatores subjetivos (relacionados ao sujeito do consentimento) e objetivos (relacionados ao contexto do consentimento) para verificar se houve voluntariedade na declaração de vontade ou se a declaração deriva de uma situação de coação, em que predomina o temor em detrimento da autonomia da vontade. Assim, exemplificativamente, deve-se analisar a capacidade, vulnerabilidade, idade, grau de instrução do sujeito (fatores subjetivos), bem como fatores como o contexto da abordagem – liberdade/detenção do abordado, duração, armamento, esclarecimentos sobre medida, ou outras circunstâncias que possam implicar formas sutis de coação (fatores objetivos), para verificar se o consentimento deve ser considerado voluntário ou produto de coação/constrangimento. Portanto, é importante notar que a coação/constrangimento ao sujeito pode ser involuntariamente provocada pelo aparato policial, em razão de simples circunstâncias objetivas da abordagem ou da condição pessoal do sujeito abordado. A coação/constrangimento não deve ser necessariamente relacionada à má-fé, ao abuso ou à truculência policial.

O constrangimento pode ser involuntariamente provocado em razão da assim denominada metus publicae potestatis, vale dizer, uma “situação em que o cidadão atua com reverência e temor quando está diante de uma autoridade pública” (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal, volume IV: Parte Especial. Rio de Janeiro: Impetus, 2007). Tal temor provocado no particular em razão da natureza do cargo ocupado pelo agente público em determinada interação (metus publicae potestatis) é então considerada pela doutrina para diferenciá-la, por exemplo, a tipicidade das condutas de corrupção passiva (CP, art. 317 – solicitar) e concussão (CP, art. 316 – exigir) por agentes públicos (nesse sentido, por todos, cf. MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal, volume 3: Parte Especial (arts. 235 a 361 do CP). São Paulo: Atlas, 2012).

Nessa ordem de ideias, deve-se ponderar que a abordagem por um grupo de policiais, fardados e armados muito provavelmente provocará no abordado uma situação de intimidação e temor – mesmo que involuntariamente, vale dizer, mesmo que eventualmente os policiais não a queiram –, notadamente quando tal abordagem tiver finalidade investigativa e em que o abordado for tratado como investigado/suspeito. Assim, tais circunstâncias objetivas da abordagem e condição pessoal do abordado culminam por afastar a voluntariedade do consentimento eventualmente declarado para a execução de medidas restritivas de direitos fundamentais, de modo a ser exigível, em tal cenário, a presença dos requisitos legais necessários para a sua execução forçada, e não consentida.

Considerações de tal ordem levaram a Suprema Corte dos Estados Unidos a, no caso Miranda v. Arizona 384 US 436 (1966), exigir a advertência expressa quanto ao direito ao silêncio e à assistência por advogado pelo indivíduo preso, a fim de assegurar a voluntariedade de eventual confissão feita em delegacia, ambiente reconhecido como intimidador.

Já em relação (ii) ao meio de comprovação do consentimento válido do morador, fixou-se a tese de que “A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo”.

A exigência da indicação de testemunhas do ato (se necessário, com o uso dos mecanismos de proteção àqueles que se sintam receosos ou ameaçados - Lei n. 9.807/99 e Decretos Estaduais n. 44.214/1999 e n. 56.562/2010, Provimento n. 32/00-CGJ/TJSP) já é positivada no art. 245, § 7º, do CPP.

De outro lado, à luz do avanço tecnológico atual, a exigência de gravação audiovisual é consectário do princípio da melhor prova (best evidente principle), o qual pode ser compreendido como ideal regulador do direito probatório e impõe às

partes o ônus de produzir a melhor prova possível (vale dizer, com maior potencial epistêmico) razoavelmente disponível a elas para a elucidação dos fatos controvertidos (sobre o tema, cf. NANCE, Dale A. The Best Evidence Principle. Faculty Publications, 1 jan. 1988. Disponível em:

https://scholarlycommons.law.case.edu/faculty_publications/463&>). Com efeito, conforme já reconhecido no julgamento da MC na ADPF 635, "há hoje tecnologias relativamente baratas e que permitem o funcionamento desse sistema [de gravação audiovisual] por meio de aplicativos de celular" (STF, MC na ADPF 635, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17.8.2020, p. 75).

Ademais, a exigência de gravação audiovisual da abordagem, para registro objetivo da regularidade da atuação policial diante do investigado, pode ainda ser compreendida como uma contrapartida pela ausência de contraditório na fase de investigação preliminar, como se esclarece na doutrina: "em relação aos meios de investigação são toleradas a surpresa e a não-observância do contraditório. [...]. Contudo, a surpresa não afasta - pelo contrário, impõe com maior rigor - a necessidade do registro formal dos resultados da investigação, independentemente de quem possa favorecer" (YARSHELL, Flávio Luiz. Antecipação da prova sem o requisito da urgência e o direito autônomo à prova. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 38-39, sem grifos no original).

Logo, ante a razoável disponibilidade de tal meio de prova (gravação audiovisual) ao aparato policial para a demonstração da regularidade de sua conduta, a omissão na sua produção resulta em lacuna probatória evitável. Tal omissão probatória imputável ao aparato policial, ao gerar dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos ocorridos na fase inquisitorial, não pode gerar prejuízo ao acusado, inclusive à luz da regra de julgamento que decorre do princípio da presunção de inocência (in dubio pro reo).

No caso, os policiais narraram em juízo que as acusadas teriam dado seu consentimento para que a equipe entrasse no imóvel, mas, (i) quanto à voluntariedade do consentimento, os relatos das rés Flávia e Sthefany são no sentido de que foram algemadas, colocadas dentro da viatura e conduzidas até a residência.

Trata-se de situação que, inequivocamente, provoca intimidação e temor - mesmo que sem intenção dos policiais -, o que fulmina a voluntariedade do consentimento eventualmente declarado para a execução de medidas restritivas de direitos fundamentais em tais circunstâncias.

Até porque, num juízo de bom senso, nada indica que as acusadas oferecessem periculosidade suficiente para que fossem algemadas. Isso porque se narra que em conduta anterior a ré Flávia havia sido encontrada na rua de sua casa e que, por consequência, ela e a namorada tinham sido abordadas. Consta que depois disso, a fim de "averiguar" a ocorrência, as rés teriam dado consentimento livre. Todavia, elas negam que o tenham feito, especialmente porque relataram que ingressaram na casa com os agentes, mas que tinham sido conduzidas dentro do veículo e algemadas. Noutro plano, ainda que assim não fosse, (ii) quanto à comprovação da voluntariedade do consentimento, verifica-se que não há registro escrito do consentimento, nem indicação de testemunhas do fato, nem gravação audiovisual do fato. Inexiste pedido de mandado de busca e apreensão ou qualquer diligência relativa à denúncia anônima que tenha sido previamente documentada, como campana ou qualquer gravação.

No ponto, vale registrar que recai sobre a acusação o ônus de comprovar a hipótese acusatória com elevadíssimo grau de probabilidade (e não sobre o acusado o ônus de comprovar a sua inocência). E mais, recai sobre os agentes policiais o ônus de comprovarem que agiram sob os ditames da lei, documentando a diligência para dar a ela a ilicitude esperada.

Isso porque a proteção da casa do indivíduo não é uma regra marginal, regulamentar ou prevista em Decretos, mas uma proteção constitucional com status de cláusula pétrea.

Logo, é cediço na jurisprudência que a busca domiciliar sem consentimento do morador deve vir acompanhada de mandado judicial, haja vista a excepcionalidade da medida, sob pena de contaminação das provas dela derivadas, conforme

consubstanciado na "teoria dos frutos da árvore envenenada".

Aliás, este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto à obtenção de provas em relação a crimes permanentes, conforme recente aresto a seguir:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPÇÃO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO. EMBASAMENTO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. LAUDO PROVISÓRIO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DOS POLICIAIS CIVIS QUE ELABORARAM O LAUDO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÕES SUPERADAS. PROVAS DECORRENTES DAQUELA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o tráfico ilícito de drogas é delito permanente, protraindo-se no tempo o estado de flagrância. 2. O ingresso da autoridade policial no domicílio para a realização de busca e apreensão sem mandado, contudo, pressupõe a presença de elementos seguros que evidenciem a prática ilícita. 3. Não se admite que a autoridade policial apenas com base em delação anônima, sem a produção de elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, viole o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, conduzindo à ilicitude da prova colhida, bem como dela derivadas, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal. 4. Considerando o nexa causal entre a prova obtida por meio ilícito, que culminou na apreensão da droga após a entrada desautorizada no domicílio do recorrente, e a decretação da prisão preventiva, ficam superadas as discussões quanto à ilegalidade da audiência de custódia realizada por videoconferência, bem como a nulidade do laudo de constatação preliminar e a decisão de prisão preventiva, pois decorrentes da prova ilícita. 5. Recurso em habeas corpus provido, a fim de anular as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar, bem como dela decorrentes, determinando o seu desentranhamento dos autos, e a revogação da prisão preventiva. (RHC 105138 / MS RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0296172-4. T6 - SEXTA TURMA. Ministro Relator: NEFI CORDEIRO. Publicado em: 10/04/2019)

Dessa forma, a prova oriunda da busca domiciliar, são ilícitas e, assim, inadmissíveis segundo o preceituado pelo artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal e artigo 157 do Código de Processo Penal.

Por isso, entendo que as provas colhidas dentro da residência são ilícitas, pela ausência de voluntariedade no ingresso, bem como pela ausência de mandado e desrespeito aos ditames legais e jurisprudenciais vigentes sobre a circunstância. Importa, portanto, fazer recorte fático.

Conquanto, embora as provas supramencionadas sejam consideradas imprestáveis, deve-se destacar que antes da busca domiciliar ocorreu a apreensão pretérita, ou seja, as provas relacionadas a abordagem policial momentos antes de ingressarem na residência da acusada deve ser apreciadas.

Isto posto, desconsidero as provas relacionadas e derivadas da apreensão domiciliar e passo a análise das demais provas produzidas nos autos.

DO MÉRITO

a) Do Tráfico de Entorpecentes

A materialidade do tráfico de drogas está bem comprovada nos autos por intermédio do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/05), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 06), Auto de Constatação Preliminar (fl. 07), Termo de Declarações (fl. 08, 10), Termo de Interrogatório (fls. 13), Nota de Culpa (fl. 14), Requisição IML (fl. 21), Requisição de Substância Entorpecente (fls. 22/23), Requisição de Objeto (fl. 24), Fotos (fls. 60/72), Relatório Final (fls. 79/81), Laudo Pericial (fls. 112/129), e, sobretudo pela prova oral, colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Quanto autoria, passo a análise a seguir:

a.1) Da autoria da ré Flávia

Interrogada, a ré Flávia Francini disse: "Estava no local do tráfico quando, por

volta das 20h30min, realizaram a abordagem. Assumi a propriedade das drogas. Eu e Sthefany fomos algemadas, colocadas dentro da viatura e conduzidas a minha residência. Lá, ingressaram na casa sem autorização utilizando as chaves que estavam comigo. Sthefany era minha companheira há cinco anos, porém não tinha ciência das drogas ou do tráfico. Da mesma forma, dona Luciane não sabia sobre as drogas. Por fim explicou: No momento dos fatos, estava colocando os kits com drogas no mato e Sthefany chegou apenas para pegar as chaves da residência.”

Interrogada, a ré Sthefani Jesus dos Santos negou a prática delitiva, disse: “Nunca trafiquei e não tinha conhecimento acerca das drogas. Morava com Flávia há cinco anos e nove meses. Conheci Luciane em Mongaguá/SP, ela veio para a cidade vender roupas. Na ocasião dos fatos, não sabia por qual motivo estava sendo abordada, fui algemada e colocada dentro da viatura. Aos questionamentos da Defesa, respondeu: No local da abordagem não havia ninguém com motocicleta”.

Interrogada, a ré Luciane Maria da Silva negou a prática delitiva, asseverou: “Tinha acabado de chegar em Eldorado quando os policiais compareceram à residência das acusadas e fui presa no mesmo dia. Os policiais realizaram buscas no local. Estava na cidade para vender roupas e voltaria para Mongaguá/SP no dia seguinte. Não tinha conhecimento sobre as drogas e a bolsa onde foram encontradas as drogas não era minha”.

A testemunha Policial Militar Edgar Santos Cunha disse: Realizamos a abordagem das acusadas em uma esquina próxima a residência delas. Indagamos Flávia sobre o restante das entorpecentes e ela indicou onde morava. As drogas estavam um terreno baldio próximo a elas. Na residência das rés, foi autorizada a entrada e Flávia mostrou onde se encontrava o restante das entorpecentes. Aos questionamentos do Ministério Público, respondeu: Flávia era apontada como traficante em vários bairros. Pouco antes da abordagem, recebemos uma denúncia que a acusada estaria traficando na antiga rua um, área pouco movimentada, no bairro Vila Nova Esperança. As drogas foram localizadas em um terreno baldio, perto de uma esquina. No instante que chegamos ao local, vimos uma pessoa em uma motocicleta conversando com a acusada, porém, o indivíduo se evadiu. Não me recordo se as rés portavam drogas, mas uma porção foi encontrada no terreno baldio. Elas assumiram a propriedade.

[...] Flávia disse que tinha drogas na residência localizada na mesma quadra. Na residência, encontramos uma senhora de mais idade, que também foi conduzida como averiguada. Ela estava no sofá onde as drogas foram encontradas. Às perguntas da Defesa, respondeu: a denúncia anônima descreveu que duas mulheres, sendo uma a Flávia, estavam vendendo drogas e que as entorpecentes se encontravam escondidas no mato. Flávia assumiu a propriedade e nos conduziu até a residência, assim, encontramos o restante das drogas na sala, onde a terceira pessoa estava.

A testemunha Joaquim Maurício Grothe Valdoski disse: Estávamos em patrulhamento quando avistamos um rapaz em uma motocicleta conversando com uma pessoa na esquina. Aproximando-se, o rapaz empreendeu em fuga, ficando apenas Flávia Francini no local. Durante a abordagem da acusada, Sthefany saiu de um matagal próximo, realizamos a revista de ambas e nada de ilícito foi encontrado, apenas uma quantia de vinte reais na posse de Flávia. Ao investigar o local em que Sthefany surgiu, encontramos um pacote com dinheiro e entorpecentes. Flávia assumiu a propriedade dos valores e das drogas e, ainda, informou o local onde estaria residindo. Por isso, conduzimos até a residência e, com a autorização da acusada, ingressamos na casa. No local estava presente uma senhora, realizamos buscas e localizamos uma porção de maconha dentro de uma caixa de sapatos que estava no quarto. Em outro quarto foi localizada uma mochila, dentro da qual havia uma boa quantidade de dinheiro, em notas diversas, bem como vários comprovantes de depósito. Entre a mochila e um saco com roupas, foi encontrada uma sacola com eppendorfs e um pacote de cocaína. [...] A abordagem ocorreu no período noturno.

A informante Maria Aparecida Jesus dos Santos asseverou: “Sthefany morava comigo no Guarujá/SP. Ela conheceu Flávia no aplicativo Facebook, que convidou para morarem juntas. Tempos depois, vizinhos da Flávia me informaram que a acusada agredia Sthefany [...] Sthefani me disse que estava traficando com a Flávia.”

Durante a instrução processual, a prova oral, consistente nas declarações das testemunhas, consubstancia sólido elemento de convencimento a demonstrar que as

condutas imputadas à acusada Flávia existiram e foram verídicas.

Em que pese haja a desconsideração das provas relacionadas ao domicílio da acusada, devem ser consideradas o conjunto probatório atinente aos fatos ocorridos anteriormente. Assim, de acordo com as circunstâncias fáticas ocorridas no terreno baldio, verifica-se que Flávia, no momento da abordagem, guardava em um matagal os entorpecentes.

A versão da acusada de que a droga lhe pertencia, em todos os momentos se comprova (art. 33 da Lei de Drogas), em especial, pelos depoimentos das testemunhas que foram corroborados pela confissão da acusada.

Conclui-se que as entorpecentes eram destinadas à traficância, considerando a variedade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento e dinheiro em espécie encontrado junto às drogas. No mais, conforme depoimento dos policiais militares, o local era pouco movimentado, algo típico de ambientes destinados ao tráfico.

Destaca-se que o depoimento das autoridades públicas tem presunção de veracidade.

E, neste caso, não há qualquer elemento que possa enfraquecer a versão de que as drogas foram apreendidas.

Do contrário, seria pressupor que o material foi implantado no local ou que as informações prestadas em Juízo são falsas, o que seria não condizente com as versões apresentadas.

Logo, do conjunto probatório coligido aos autos não pairam dúvidas de que, de fato, as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam e eram destinadas à traficância.

a.2) Da autoria das rés Sthefany e Luciane

No que tange à autoria das rés, não ficou demonstrado que tenham praticado a conduta em questão.

Em seu interrogatório, a ré Sthefany negou a prática delitiva e demonstrou desconhecimento sobre as drogas apreendidas. Esse fato foi corroborado pelo depoimento da ré Flávia, pois mencionou que, embora tivesse um relacionamento com a acusada, ela não tinha ciência das drogas.

Em que pese os policiais militares tenham mencionado que avistaram a ré próxima ao local onde as drogas foram localizadas, pairam dúvidas sobre o motivo de Sthefany estar presente no local dos fatos, haja vista que Flávia asseverou em juízo que a ré foi até o local apenas para buscar as chaves da residência.

No mais, o simples fato de estar próxima ao ambiente que seria destinado ao tráfico de drogas não pode ser usado como prova única e exclusiva para sua condenação.

Evidentemente, faz-se necessário a presença de outros elementos probatórios que possam comprovar a prática delitiva e, no presente há ausência de demais provas que possam imputar a autoria à acusada.

No tocante a ré Luciane, considerando que as provas produzidas visando comprovar a autoria da acusada estão relacionadas com a violação de domicílio, os elementos probatórios desenvolvidos nesse contexto tornam-se imprestáveis como mencionado anteriormente. Por consequência, inexistem provas que possam imputar a autoria da ré sobre os fatos narrados na denúncia.

Até porque, quanto à ela, nada mais foi produzido ou mencionado e ainda que as provas fossem lícitas, seriam frágeis para autorizar o decreto condenatório.

Cumprir registrar que pelo princípio da verdade real, a condenação criminal exige certeza matemática e, se esta certeza não é alcançada, ainda que no mundo real o crime tenha sido de fato praticado por aquele que está sendo acusado, a absolvição é de rigor. Como afirmou o Mestre NELSON HUNGRIA, "condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente".

Logo, incerta a autoria, não exsurge a certeza necessária à condenação, face ao princípio constitucional do estado de inocência, do qual é corolário o princípio do in dubio pro reo. Imperativa, portanto, a absolvição dos acusados, eis que: "O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o juiz criminal proferir condenação" (TJSP, Ap. nº 162.055, 5ª Câmara, v.u., rel. Goulart Sobrinho).

b) Associação para o tráfico

Quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), entendo, prescreve o art. 35 da Lei de Drogas:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 10, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência para a comercialização de drogas, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário.

Nessa toada, o delito de associação para o tráfico de drogas exige a estabilidade da associação criminosa entre dois ou mais agentes, mediante a divisão de atribuições com a finalidade de praticarem o comércio ilegal de substâncias entorpecentes de forma estável e permanente.

No caso dos autos, após a colheita de todo o arcabouço probatório, entendo que não ficou evidente que as rés estavam reunidas com a intenção de estabilidade e permanência criminosa.

A divisão de tarefas entre elas não estava distribuída, sendo que, pela audiência, o único ponto comum afirmado pelos policiais era o de que, supostamente, eles estariam comentando condutas criminosas.

Informaram que o souberam por meio de denúncias anônimas, mas nada há que tenha delineado o tempo da reunião, a finalidade, os meios executados.

Isso porque, apesar de os Policiais terem noticiado que avistaram Sthefany próximo ao local onde foram encontradas as drogas e que Luciane estava na residência onde foi localizada as demais entorpecentes, nada narraram em seus depoimentos sobre como elas agiam. Ou seja, o depoimento limitou-se a descrever a operação policial e a apreensão da droga.

O Ministério Público, como detentor da prova, segundo o sistema acusatório, também se limitou a perguntar a respeito da apreensão, sem colher elementos sobre a suposta associação para o tráfico.

Muito embora a associação possa ser realizada por, no mínimo, duas pessoas, é necessário o convencimento do Juízo de que havia estabilidade e permanência, segundo provas extraídas da fase processual e não apenas do inquérito.

É preciso, ainda, que os depoimentos testemunhais sejam claros e que não se conclua meramente por probabilidade, mas por um juízo límpido do fato que se está a averiguar.

Nada ficou apurado sobre como supostamente agiam, além do fato de que, eventualmente, estavam praticando tráfico em concurso de pessoas.

Cumpra registrar que a simples existência de condenação pretérita por delito de igual natureza não pode ser usada como elemento exclusivo de prova, sob pena de bis in idem.

Por fim, o simples fato de serem um casal, o que importa em proximidade afetiva, não implica em unicidade de desígnios para o fim de cometer delito de associação para o tráfico.

Assim, a autoria do delito de associação para o tráfico não está comprovada.

c) Aplicação do privilégio

Importante ainda ressaltar que, muito embora a ré Flávia não tenha sido condenada nestes autos por associação, fato é que já cumpriu pena pelo delito de tráfico de drogas em data pretérita. Nesse sentido inclina-se a jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há como ser aplicada a minorante

prevista no § 4º do art. da Lei de Drogas em favor do recorrente, haja vista a vedação legal expressa da concessão dessa benesse aos acusados reincidentes. 2. O reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, não é incompatível com a sua utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito perpetrado. Não há falar, portanto, em bis in idem. Precedentes. 3. Agravamento regimental não provido. Destarte, de tudo o que foi exposto, tem-se que o acervo probatório é vasto e suficiente para ensejar a condenação da acusada na conduta de tráfico de drogas, sem a forma privilegiada.

III - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Passo à individualização das penas em consonância com o artigo 68 do Código Penal. Na primeira fase da dosimetria das penas devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, a saber: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, as suas circunstâncias e consequência, e o comportamento da vítima.

1 fase: A sentenciada apresenta uma circunstância negativa consistente naquela prevista no art. 42 da Lei de Drogas, relativamente à natureza e quantidade. Por terem sido recolhidas mais de uma substância entorpecente, reputo essa circunstância como negativa. Considerando a diversidade das substâncias, importa em acréscimo de 1/6 (um sexto) calculado sobre a pena em abstrato. Assim sendo, quanto ao crime de tráfico de drogas FIXO a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2 fase: Na segunda fase da dosimetria das penas a sentenciada incide na agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, podendo ser considerada reincidente, conforme autos nº 0001148-59.2016.8.26.0172, que transitou em julgamento antes da prática dos fatos ora apurados, conforme certidões de fls. 382. Por outro lado, a ré confessou a prática delitativa, incidindo a atenuante da confissão, por consequência, a agravante e atenuante se compensam. Mantenho a pena anteriormente fixada.

3 fase: Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena. Fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista os parâmetros dispostos no artigo 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, tal qual acima alinhavado, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o fechado, sobretudo porque amplamente desfavoráveis as circunstâncias judiciais e a reincidência. Ausentes informações sobre a situação econômica da acusada, o valor do dia-multa deve corresponder ao mínimo legal.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para:

a) CONDENAR FLÁVIA FRANCINI DA COSTA, qualificada nos autos, pelo crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; E ABSOLVER a sentenciada pelo crime do artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006.

b) ABSOLVER LUCIANE MARIA DA SILVA e STHEFANY JESUS DOS SANTOS pelos crimes dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Inviável o deferimento dos benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal, eis que os acusados não preenchem os requisitos legais, sobretudo em vista das circunstâncias judiciais desfavoráveis e o quantum da pena.

INDEFIRO o direito da ré apresentar recurso em liberdade, mantendo a prisão decretada nestes autos, pelos fundamentos já expostos e objeto de reavaliação noventenária, nos termos de recente decisão, cuja fundamentação reitero.

EXPEÇA-SE guia de execução provisória.

Providencie-se, também, após o trânsito em julgado, a expedição da guia de recolhimento para execução definitiva (artigos 105 e 106, da Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210/84, artigo 703 do Código de Processo Penal e artigos 467 a 469 das NSCGJ); as comunicações de estilo ao IIRGD e à Justiça Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição da República).

Condene a ré a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Eldorado, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA